

0012796-77.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Violação de direito autoral

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... pois foi condenado definitivamente por tráfico de drogas nos autos nº 0055188-95.2018.8.26.0050, junto à 1ª Vara Criminal Central da Capital, tendo o trânsito em julgado para defesa ocorrido em 22/08/2013 (fls. 121); foi condenado definitivamente por furto qualificado nos autos nº 0103004-54.2010.8.26.0050, na 5ª Vara Criminal Central da Capital, tendo transitado em julgado para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - cep 01133-020

TERMO AUDIÊNCIA

Processo nº

0012796-77.2017.8.26.0050 - Controle: 2021/000942

Réu

JOSE SEVERINO FARIAS FILHO

Aos 05/05/2022, às 15:30h, por força do Provimento 2564/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo TEAMS, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, PRESENTES os réus JOSE SEVERINO FARIAS FILHO.

Presente o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo e o(a) Defensor(a) Público(a) em exercício nesta vara, Dr. Rafael Zambon de Moraes.

Antes do início dos trabalhos as partes foram indagadas a respeito da realização do ato de forma virtual e não se opuseram, afirmando que não há qualquer prejuízo.

Após ser(em) entrevistado(s) pelo(a) Defensor(a), depois de cientificado(s) da acusação e, ainda, do direito de permanecer(em) calado(s) (art.5º, LXIII, da Constituição Federal e art. 186 do Código de Processo Penal), passou(ram) o(s) réu(s) a ser(em) INTERROGADO(S) de acordo com o artigo 188, I e VIII, do Código de Processo Penal.

Pelas partes foi dito que nada havia a requerer na fase do art. 402, do C.P.P.

A seguir pela MM Juiz(a) de Direito foi dito: "Inexistindo outras provas a produzir, declaro encerrada a instrução criminal, abrindo-se os debates, na forma do art. 403 do C.P.P".

Na sequência, foi dado início aos debates, dada a palavra a(o) Promotor(a) de Justiça, por este foi dito que: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JOSÉ SEVERIANO FARIAS FILHO como incurso nas penas do artigo 184, §2º, do Código Penal, porque no dia 06 de maio de 2016, por volta das 11h, na Rua Pilar do Sul, nº 115, José Bonifácio, São Paulo - SP, adquiriu, tinha em depósito e expunha a venda, com o intuito de lucro, cópia de fonogramas, consistente em 629 (seiscentos e vinte e nove) mídias diversas entre CD's e DVD's, reproduzidos com violação de direito autoral - v. denúncia - fls. 116/118. Recebimento da denúncia

(fls. 144). Resposta à acusação (fls. 156/158). Citação (fls. 153). Audiência de instrução e julgamento, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório. Encerrada a instrução, vieram os autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais. É o relatório. Pedese a condenação do acusado. Autoria e materialidade delitiva ficaram provadas. A materialidade delitiva ficou provada, considerando-se especialmente boletim de ocorrência de fls. 04/05, auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo pericial de fls. 07/10. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima (na fase policial e em juízo) e pelos depoimentos das testemunhas. Da prova oral reproduzida em juízo. Não houve oitiva de testemunhas. Interrogado em juízo, o acusado disse que realmente comprou as mídias piratas e estava vendendo-as na feira no local dos fatos. Confessou a prática delitiva (v. mídia digital respectiva). Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos quando avistaram em uma feira livre, uma barraca com diversos CD's e DVD's expostos a venda, aparentemente originados com violação do direito autoral – piratas. Diante dos fatos, realizaram a abordagem do responsável pela barraca, identificado como sendo o acusado, encaminhando a ocorrência a autoridade competente para registro da ocorrência. Realizada perícia, a conclusão foi no sentido que se tratavam de peças não autênticas, fls. 07/10. Interrogado, o acusado reservou seu direito de somente se manifestar em juízo, fls. 66/67. Como visto, é caso de condenação. Resta apenas consideração sobre pena e regime a serem fixados em caso de condenação, do ponto de vista ministerial. Na 1ª fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes criminais, tendo em vista que o acusado já foi condenado definitivamente por furto nos autos nº 005433-88.2007.8.26.0050, na 19ª Vara Criminal Central da Capital, tendo o trânsito em julgado para defesa se dado em 27/04/2009 (fls. 119/120); por furto qualificado nos autos nº 0008654-11.2009.8.26.0050, na 31ª Vara Criminal Central da Capital, tendo o trânsito em julgado para defesa se dado em 13/07/2010 (fls. 120); bem como está respondendo por furto qualificado nos autos nº 0066483-86.2005.8.26.0050, junto à 2ª Vara Criminal Central da Capital, tendo sido revogado a suspensão condicional do processo, vez que o acusado está preso por outro processo (conforme documento em anexo). Na 2ª fase, a pena deve ser majorada em razão da multirreincidência do acusado, pois foi condenado definitivamente por tráfico de drogas nos autos nº 0055188-95.2018.8.26.0050, junto à 1ª Vara Criminal Central da Capital, tendo o trânsito em julgado para defesa ocorrido em 22/08/2013 (fls. 121); foi condenado definitivamente por furto qualificado nos autos nº 0103004-54.2010.8.26.0050, na 5ª Vara Criminal Central da Capital, tendo transitado em julgado para defesa em 04/04/2013 (conforme documento em anexo). Na 3ª fase, inexistente causa de aumento ou de diminuição. O regime prisional inicial pode ser o semiaberto, nos termos do art. 59, III, do CP. Posto isto, pede-se a condenação de JOSÉ SEVERIANO FARIAS FILHO como incurso nas penas do artigo 184, §2º, do Código Penal."

Pelo defensor do réu foi apresentada sua alegação final através de manifestação colhida por meio audiovisual.

Pela MM.<sup>a</sup> Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: "JOSÉ SEVERINO FARIAS FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 184, § 2º, do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 06 de maio de 2016, por volta das 11 horas, na Rua Pilar do Sul, 115, adquiriu, tinha em depósito e expunha a venda, com o intuito de lucro, cópia de fonogramas, consistente em 629 (seiscentos e vinte e nove) mídias diversas entre CD's e DVD's, reproduzidos com violação de direito autoral, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de fls. 07/10. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou sua defesa previa. Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que apenas o réu foi ouvido. Encerrada a instrução criminal em fase de debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição do acusado. Não obstante o esforço do combativo membro do Ministério Público, o caso é de improcedência da ação penal. No caso em concreto, sequer restou provado que o réu foi apreendido com as mídias mencionadas, por primeiro, porque, os policiais

citados no boletim de ocorrência não foram arrolados para serem ouvidos sob o crivo do contraditório. Por outro lado, apesar do réu ter dito que realmente comprou os CDs piratas e resolveu vendê-los para tentar o sustento de sua família, e confessar o crime não basta para esta magistrada, que alguém seja detido na posse ou comercializando videofonogramas não autênticos, tratando-se de reproduções grosseiras, desprovidas das características de originalidade descrita no capítulo "dos padrões de confronto", para, com base somente nisso, obter a condenação do acusado. Com efeito, além da apreensão desse material em poder de alguém e além de uma perícia constatando sua baixa qualidade a indicar ser ele pirateado, a verdade é que compete ainda ao órgão acusador (no caso, o Ministério Público) provar também que o material apreendido (CDs, DVDs, etc.) constitui obra intelectual protegida nos termos da legislação vigente, demonstrando ainda quem é o titular do direito autoral afrontado. Afinal, se esse material, se esses videofonogramas não constituírem obras intelectuais protegidas nos termos da legislação vigente, titularizadas por pessoa conhecida, identificada, viva (ou por seus sucessores) não há que se falar em crime de violação de direito autoral. De se observar, nesse sentido, que as obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores não são objeto da proteção a que se destina o presente processo criminal (art. 45, I, da Lei n. 9.610/98). Da mesma maneira, não são objeto dessa proteção as obras de autor desconhecido (art. 45, I, da Lei n. 9.610/98) e as obras que caíram no domínio público em virtude do decurso dos prazos mencionados nos artigos 41 a 44, I, da Lei n. 9.610/98. Além disso, e apenas para deixar claro que a proteção legal que embasa o presente procedimento criminal não é absoluta, havendo hipóteses concretas nas quais ela não se aplica, cabe ainda mencionar que um músico, um grupo, uma banda, enfim, qualquer pessoa poderia compor uma música, fazer um clip, um show, um curta ou até um filme, gravar essas obras e disponibilizá-las a terceiros através de CDs, DVDs ou mesmo pela Internet em sites como o youtube.com (v.g.), sendo certo que a reprodução e eventual comercialização dessas obras não configuraria crime algum já que permitida tacitamente pelo autor. Diante disso, é certo que, em casos como o dos presentes autos não basta simplesmente proceder a apreensão de materiais supostamente pirateados, cabendo ainda ao Ministério Público produzir prova efetiva, documentada, de que: (a) esses materiais apreendidos (CDs, DVDs, etc) constituem obras intelectuais protegidas; (b) a proteção legal sobre tais obras está vigente; (c) os titulares desses direitos protegidos são conhecidos, identificados; (d) os titulares desses direitos protegidos estão vivos; e (e), caso tenham morrido, que deixaram sucessores. Apesar de ser trabalhosa, a produção dessa prova não é impossível. O que não se pode aceitar é que, ante o trabalho que deve ser enfrentado para que se produza tal prova e que, ante a ausência de produção efetiva dela, seja alguém, mesmo assim, processado e condenado. Observe-se, neste ponto, que o próprio ECAD (que por força da Lei nº 5.988/73, passou a centralizar toda a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, além de toda a documentação necessária para o desenvolvimento do processo), para distribuir os proventos advindos da veiculação de obras de seus associados, exige, entre outras coisas, a prova da filiação do autor, do cadastramento da respectiva obra e da execução pública dessa obra. No mesmo sentido, aliás, são as recomendações encontradas nos sites [www.brasilmarcasepatentes.com.br](http://www.brasilmarcasepatentes.com.br) e [www.patentnet.com.br](http://www.patentnet.com.br). Ora, se até mesmo em sede administrativa são tomadas várias cautelas relativas à prova da existência, vigência e titularidade dos direitos autorais, não se pode aceitar que, em sede de procedimento criminal, no qual os valores envolvidos são mais importantes (v.g.: liberdade humana), se atue com menor cautela e que, ante a ausência dessa prova, se processe alguém visando sua condenação. Infere-se de todo o exposto que para que seja proposta uma ação penal em casos como o presente é absolutamente indispensável à prova de que o material apreendido foi efetivamente produzido com violação a direitos autorais. Por outro lado, segundo o auto de fls. 06 foram apreendidos "por volta" de 629 mídias diversas e 102 CDS, e conforme o laudo de fls. 07/10, e somente 41 mídias é que foram devidamente analisados. Não sendo sequer neste sentido apta a prova produzida uma vez que não há como se estabelecer uma exata correspondência entre os objetos apreendidos e aqueles realmente periciados. Veja-

se ademais, que não há sequer menção à titularidade do direito autoral e necessária se torna consulta junto às associações de proteção dos direitos autorais, no sentido de se verificar ou identificar as propriedades violadas, não se tratando de matéria técnico-científica. Há que se considerar ainda a versão das testemunhas ouvidas. Assim é que os dois policiais ouvidos nesta data apenas disseram que faziam uma operação no local e que viram o acusado comercializando CD's. Não souberam dizer quantos eram os objetos nem mesmo como foi feita a perícia. Stemo chegou, inclusive a mencionar que o acusado, assim como todos os outros que ali se encontravam, estavam trabalhando, pois não conseguiam se firmar no mercado formal de trabalho. Por conseguinte, está ausente a justa causa para a ação penal. Digno de nota, neste ponto, que cabe ao Juiz, no momento do recebimento da denúncia, averiguar o *fumus boni iuris* necessário para a instalação da persecução penal, eis que a mesma inegavelmente afeta o status dignitatis do acusado, sendo que "desse controle não deve o juiz ser afastado, porque o direito de defesa, que é garantia constitucional, torna imperativo que se evitem procedimentos temerários e infundados. Não há no caso, um juízo de formação de culpa, uma apuração rigorosa do corpo de delito (...) O que existe é um despacho de deliberação provisório e simples, em que o juiz apura se há fumaça do bom direito que autorize a instauração da *persecutio criminis* em sua fase processual." Ademais, "O Direito não é ciência subordinada aos cânones inflexíveis da Lógica Matemática, e, sim, aos preceitos dúcteis do razoável - daquele *logos del zanonable* de que fala RECASENS SICHES. Daí sobrar, em certas situações, esse resíduo de apreciação discricionária na aplicação dos imperativos da ordem jurídica. O processo penal atinge o status dignitatis do acusado. Em vários casos, este sacrifício é exigido, como acontece sempre que o réu é absolvido, no interesse do bem comum. Todavia, se nem o *fumus boni iuris* pode descobrir-se, para alicerçar a peça acusatória, seria iníquo que o juiz permanecesse impassível e, como simples autômato, fosse recebendo a denúncia ou queixa. Esse despacho de deliberação requer, sem dúvida, muito equilíbrio e ponderação, pois, do contrário, a função repressora do Estado acabaria estancando-se, com grave prejuízo para o interesse comum e a segurança da vida social. Mas o juiz é, sobretudo o homem prudente que deve saber dosar, com sabedoria e descortino, o exercício de suas funções, notadamente quando está em jogo, pela flexibilidade da situação jurídica que se lhe apresenta, o seu arbítrio de bom varão. Se podemos confiar na opinião *delicti* em que se apóia o Ministério Público, porque não fazer o mesmo com o *arbitrium bonni viris* do juiz?". (in MARQUES, José Frederico. Estudos de Direito Processual Penal, Ed. Forense, 1ª ed., 1960, p.147/148)". Diante de todo o exposto, é o caso de se absolver o acusado com base no art. 386, inciso III, combinado com art. 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Autorizo, desde já a destruição das mídias apreendidas (fls. 16) nos termos do que dispõe o art. 530 F do Código de Processo Penal. Oficie-se neste sentido." Sentença publicada em audiência. Pelo acusado e por seu(sua)(s) defensor(a)(e)(s) foi dito que não desejam recorrer. Pelo Ministério Público foi dito que não deseja recorrer. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: Nesta data fica certificado o trânsito em julgado para a Defesa e para o Ministério Público. Verifique a serventia se há bens pendentes de destinação, certificando-se. Em caso positivo, dê-se vista ao Ministério Público. Revogo as medidas cautelares anteriormente impostas. Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas anotações e comunicações.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pela MMª Juíza, consoante o disposto no art. 1.269 das Normas da Corregedoria do TJSP. Os depoimentos prestados em audiência estão documentados em mídia audiovisual, que permanecerá disponibilizada em links de acesso neste termo. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo. Saem todos cientes do teor do presente termo. Eu, DANIELA DE OLIVEIRA MAROUBO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves  
Promotor(a): Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo

Defensor(a): Dr. Rafael Zambon de Moraes  
Réu: JOSE SEVERINO FARIAS FILHO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA